

2025년 시행 변리사 2차 시험

민사소송법 기출문제 강평 및 해설

- 한빛 변리사 김종연 -



【제1문】 (30점)

甲은 A로부터 X 토지(이하 '이 사건 대지'라 한다)에 대한 소유권을 취득하였는데, 그 이전부터 乙이 위 지상에 Y 건물을 소유하고 있었다. 그 후 甲과 乙 사이에는 위 건물의 소유를 목적으로 이 사건 대지에 대하여 임대차계약을 체결하였다. (다음 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 이 사건 대지의 임대차 기간이 종료하여 乙이 계약의 갱신을 청구하였으나, 甲은 계약의 갱신을 원하지 않는다. 甲이 임대차 기간 종료를 원인으로 위 건물의 철거 및 이 사건 대지의 인도를 구하는 소를 제기하였다. 이에 대하여 乙이 이 사건 변론에서 甲에게 상당한 가액으로 위 건물을 매수할 것을 청구하였다. 법원은 甲과 乙 사이에는 위 건물에 대하여 시가 상당액을 대금으로 하는 매매가 이루어졌다고 판단하였다. 이 경우 법원은 甲의 청구에 대하여 어떠한 판결을 하여야 하는지를 검토하시오. (10점)

설문 (1)에 대한 간단한 해설

제203조 처분권주의 문제입니다. 법원의 판결을 묻고 있기 때문에, 소변경 석명에 따른 상환이행판결은 별론으로 하고, 법원은 乙의 건물매수청구권의 행사가 적법하여 매매가 이루어졌다고 판단하였습니다. 이에따라 법원이 상환이행판결을 할 수 있는지 여부가 문제됩니다. 목차구성은 다음과 같습니다.

1. 쟁점의 정리

2. 처분권주의의 의의와 내용

3. 법원의 상환이행판결 가부

- (1) **학설 및 판례** - 이에 대하여 i) 분쟁의 1회적 해결을 위해 긍정하여야 한다는 견해가 있으나 ii) 판례는 임대차 종료시 임대인의 건물철거 및 토지인도청구 속에는 건물의 매수대금지급과 상환으로 건물인도를 구하는 청구가 포함되어 있다고 볼 수 없으므로, 법원으로서 원고에게 매매대금지급과 상환으로 건물명도를 명하는 판결을 할 수 없다고 하여 부정설의 입장이다. 다만, 토지임대인의 임차인 상대의 지상물철거 및 토지인도청구소송에서, 임차인이 건물매수청구권을 행사하고 심리 결과 그 권리가 인정된다면 임대인의 건물

철거 및 대지인도청구는 기각당할 수 밖에 없으므로, 법원은 임대인에게 종전의 건물철거청구를 유지할 것인지 아니면 대금지급과 상환으로 건물인도를 청구할 의사가 있는지에 관해 석명의 무가 있다.

(2) 검토 및 사안

4. 사안의 해결 - 법원의 조치가 아닌 법원의 판결을 묻고 있기 때문에, 법원의 적극적 석명은 간단하게 기재하는 것을 추천드립니다. 즉, 법원의 상환이행판결은 불가하며, 청구기각 판결을 할 수밖에 없으나, 이에 대한 석명의무 위반 소지가 있다는 논의로 전개하는 것이 출제자의 의도에 부합하지 않나 생각합니다. 이런 이유로 석명 목차는 따로 구성하지 않았습니다. 실전모의고사에서도 의도적으로 상환이행판결의 적법 여부만을 묻는 문제를 출제하였고, 2025년 기출문제에서 출제자의 의도는 처분권주의와 관련된 상환이행판결 논의를 주요쟁점으로 삼았으며, 법원의 적극적 석명권 행사 여부는 주요쟁점으로 삼지 않은 것으로 보입니다.

실전모의고사 A반 4회 참고

甲은 경기도 가평에 소재하고 있는 자신 소유의 A토지 위에 乙이 아무런 권원도 없이 무단으로 B건물을 신축한 것이라고 주장하면서 乙을 상대로 건물철거 및 토지인도를 청구하는 소를 제기하였다. (다음 각 물음은 독립적임)

(1) 위 소송에서 乙은 “甲과의 토지임대차계약에 따라 B건물을 신축한 것”이라고 주장하며, 甲이 갱신요청을 거절하였음을 이유로, 건물매수청구권을 행사하였다. 법원은 乙의 건물매수청구권의 행사가 이유 있음을 들어 다음과 같은 판결을 선고하였다. 법원의 판결이 적법한지 설명하시오. (10점)

주 문

1. 피고는 원고로부터 200,000,000억 원을 지급받음과 동시에 원고에게 별지목록 기재 건물을 인도하라.
2. 소송비용은 2분의 1은 원고가, 나머지는 피고가 부담한다.
3. 위 제1항은 가집행할 수 있다.

(2) 甲은 乙을 상대로 Y 건물의 철거청구 소송을 진행하던 중 乙로부터 이 건물의 소유권을 이전받은 丙을 인수승계 신청하면서 丙에 대하여는 소유권이전등기를 말소하라는 소를 제기하였다. 이 경우에 법원은 甲의 인수승계 신청에 대하여 어떠한 결정을 하여야 하는지를 검토하시오. (10점)

설문 (2)에 대한 간단한 해설

제82조 교환적 인수승계의 문제입니다. 법원의 결정을 묻고 있기 때문에, 인수승계의 일반론과 교환적 인수 및 추가적 인수 내용을 서술하고 **추가적 인수승계 가부에 대한 논의를 거쳐, 법원은 甲의 인수승계 신청에 대하여 불허가결정을 내려야 합니다.** 목차구성은 다음과 같습니다.

1. 쟁점의 정리

2. 인수승계의 의의 및 요건

- 승계인 범위와 관련하여 i) 소송물을 승계한 자와 ii) 계쟁물을 승계한 자에 대한 논의를 간단하게 기재한 후 사안에서 丙은 계쟁물 승계인에 해당한다는 점을 밝히고, 교환적 인수는 문제되지 않음을 기재한 후, 추가적 인수의 인정 여부 논의로 전환하시면 됩니다.

3. 추가적 인수의 인정 여부

(1) **학설 및 판례** - 이에 대하여 i) 이를 불허한다면 별도의 소를 제기하게 되는 **불경제를 초래하므로 인정하여야 한다는 긍정설**, ii) 계쟁물에 의한 추가적 인수를 인정할 경우 **당사자의 변경뿐만 아니라 청구변경도 초래되어** 소송승계 제도 본래의 목적을 넘어 청구가 부당하게 확대되고 심리의 복잡화를 초래하므로 이를 **인정할 수 없다는 부정설**, iii) 공유물 분할청구소송과 같은 고유필수적 공동소송의 경우에는 청구변경이 초래되는 것은 아니므로 예외적으로 교환적 인수와 추가적 인수를 모두 인정할 수 있다는 절충설의 견해가 대립한다. iv) 판례는 **‘건물철거청구 중에 피고가 제3자 앞으로 그 건물에 대한 소유권이전등기를 넘길 경우에 제3자 명의의 등기말소 의무의 이행을 구하기 위한 소송인수신청은 허용될 수 없다’**고 하여 부정설의 입장이다.

(2) 검토 및 사안

- 4. 사안의 해결** - 실전모의고사에서는 계쟁물 승계인으로 공유지분을 양수받은 자를, 소송물 승계인으로 면책적 채무인수를 풀어보았습니다. 모범답안에서도 승계인의 범위와 유형 파악이 핵심이라고 언급하였는 바 사안은 명확하게 판례가 부정한 사안이기 때문에, 긍정설 보다는 **부정설에 따라 법원의 인수신청 불허가결정으로** 결론을 내리시는 것을 추천드립니다.

실전모의고사 A반 5회 참고

甲과 乙, 丙은 3층으로 된 X건물을 1/3 지분씩 공동으로 소유하고 있다. 甲은 乙과 丙에게 X건물을 매각하자고 말하였으나, 乙과 丙은 매각을 반대하였다. 이에 甲은 乙과 丙을 상대로 X건물에 대하여 매각분할을 구하는 취지의 공유물분할청구의 소를 제기하였다. (다음 각 물음은 독립적임)

- (2) 제1심 법원의 심리결과 소송계속 중 丙이 A에게 자신의 공유지분을 양도하고 지분권 이전의 등기까지 마친 사실이 밝혀졌다. 甲이 공유물분할청구의 소를 계속 진행시키기 위해 취할 수 있는 가장 효율적인 소송법상 방안을 설명하시오. (10점)

실전모의고사 B반 5회 참고

甲은 乙에 대하여 2024. 1. 1. 변제기가 도래한 2억 원의 대여금 채권을 가지고 있다. (다음 각 물음은 독립적임)

- (2) 甲은 乙을 상대로 대여금의 지급을 구하는 소를 제기하였는데, 위 소송계속 중에 丙은 乙로부터 乙이 부담하는 대여금 채무를 면책적으로 인수하는 계약을 체결하였다. 甲은 丙이 소송의 목적인 대여금 채무를 승계한 것으로 보고 丙으로 하여금 위 소송을 인수하게 할 것을 신청하였고, 법원은 甲의 인수신청을 받아들여 인수결정을 하였다. 위 소송이 계속 심리되던 중에 乙의 대여금 채무를 면책적으로 인수한 것은 丙이 아니라 丁이라는 사실이 밝혀졌다. 이 경우 법원은 어떠한 판결을 하여야 하는지 설명하시오. (13점)

(3) 甲이 乙을 상대로 이 사건 대지의 인도를 구하는 소(이하 '전소'라 한다)를 제기하여 승소판결을 받아 위 판결이 확정되었다. 그 후 甲이 乙을 상대로 Y 건물에 관한 철거청구의 소(이하 '후소'라 한다)를 제기하였는데, 후소에서 乙이 전소의 변론종결일 전부터 존 재하던 건물소유 목적의 이 사건 대지임차권에 기하여 건물매수청 구권을 행사하였다. 이에 대하여 甲은 전소의 기판력에 저촉된다고 주장하였다. 이 경우에 법원은 어떠한 판단을 하여야 하는지를 검토하시오. (10점)

설문 (3)에 대한 간단한 해설

기판력의 시적범위와 관련하여 건물매수청구권의 실권효 문제입니다. 기판력 일반론과 시적범 위 관련 차단효 내용을 서술하고, 건물매수청구권의 실권 여부 논의를 거쳐, **법원은 기판력 에 저촉되지 않음을 이유로 철거청구소송에 관한 본안판단에서 건물매수청구권의 당부 도 함께 판단**을 하여야 합니다. 목차구성은 다음과 같습니다.

1. 쟁점의 정리

2. 기판력의 작용과 구체적 범위

(1) 기판력의 의의와 작용

(2) **기판력의 구체적 범위** - 기판력의 시적 범위와 관련하여 차단효와 실권효 내용을 논의 한 후 민사집행법 제44조도 법적 근거로 제시하는 것을 추천드립니다.

3. 건물매수청구권의 실권 여부

(1) **학설 및 판례** - 이에 대하여 i) 분쟁을 일거에 해결하여야 한다는 소송경제측면에서 차단되어야 한다는 **실권설**, ii) 알고도 행사하지 않은 경우에는 실권된다는 **절충설**의 견해 가 있으나, iii) **통설은 강력한 정책적 견지에서 인정된 권리이므로 그 시기를 정하는 것은 적절치 못하다는 비실권설의 입장**이다. iv) 판례도 임대인의 임차인을 상대로 한 토지인도 및 건물철거소송에서 임차인이 패소확정을 받았다 하여도, 건물철거가 집행되지 아니한 이 상 토지의 임차인으로서 전소에서 행사하지 아니한 **건물매수청구권을 행사하여 별도의 소로써 임대인에 대하여 건물매매대금의 지급을 구할 수 있다**고 하였다. 그러므로 전소인 토지인도 및 건물철거 청구소송과 후소인 매매대금 청구소송은 서로 소송물을 달리하는 것 이므로, **종전 확정판결의 기판력에 의하여 건물매수청구권의 행사가 차단된다고 할 수 없으 며**, 뒤늦게 건물매수청구권을 행사하는 것이 **권리남용이거나 신의칙에 위배되지 않는다고** 하여 비실권설의 입장이다.

(2) 검토 및 사안

4. 사안의 해결 - 실전모의고사에서도 기판력의 저촉여부로 풀어보았으나, 2025년 기출문제는 기판력에 저촉된다는 주장을 하였고, 이에 대한 법원의 판단을 묻고 있습니다. 법원의 구체적인 판결을 묻고 있는 것이 아니므로, 출제자의 의도에 맞게 기판력에 저촉된다는 甲의 주장은 부당하다는 판단을 전제로 본안판단에서 건물매수청구권의 행사가 적법하다면 청구기각의 판결을, 부적법하다면 청구인용의 판결을 각각 나누어 기재하는 것이 득점에 유리할 것으로 생각됩니다.

실전모의고사 A반 4회 참고

甲은 경기도 가평에 소재하고 있는 자신 소유의 A토지 위에 乙이 아무런 권원도 없이 무단으로 B건물을 신축한 것이라고 주장하면서 乙을 상대로 건물철거 및 토지인도를 청구하는 소를 제기하였다. (다음 각 물음은 독립적임)

(2) 위 소송에서 甲의 청구인용판결이 선고되어 확정되었다(이하 ‘전소’라고 한다). 그 후 甲이 B건물의 철거를 집행하려 하자 乙은 甲을 상대로 임차권을 주장하며 B건물의 매수청구와 함께 매매대금의 지급을 구하는 소를 제기하였다(이하 ‘후소’라고 한다). 乙의 건물매수청구권의 행사요건이 갖추어졌다고 할 때, 乙의 건물매수청구권의 행사가 전소 기판력에 저촉되는지 설명하시오. (10점)

【제2문】 (20점)

甲과 A는 X 부동산(이하 ‘이 사건 부동산’이라 한다)의 공유자로서 공동으로 乙을 상대로 이 사건 부동산의 인도를 구하는 소를 제기하여 제1심에서 승소판결을 받았다. 乙의 항소로 이 사건이 항소심에 계속중인 2023. 10. 23. A가 사망하였다. A의 상속인으로는 甲과 丙, 丁이 있다. (다음 각 물음은 독립적이다.)

- (1) A에게는 소송대리인은 없으며, 2024. 1. 30. 甲만 수계신청하여 본안에 관한 심리가 진행된 끝에 항소심법원은 甲만을 A의 소송수계인으로 하여 판결을 선고하였다. 甲의 이 사건 수계신청이 적법한지와 丙과 丁에 대한 관계에서 그 소송은 어떻게 되는지를 검토하시오. (10점)

설문 (1)에 대한 간단한 해설

제233조 소송절차의 중단 및 수계와 제66조 통상공동소송에 관한 문제입니다. A의 사망에 따라 甲, 丙, 丁이 당연승계하여 소송절차는 중단되며, 통상공동소송에 해당하여 제66조가 적용되므로 개별적인 수계가 가능하다는 내용을 기재하고, 丙과 丁에 대한 관계에서는 소송절차가 중단된 채 항소심에 계속되어 있음을 논의하시면 됩니다. 【2문】은 질문이 구체화 되었으므로, 질문을 활용한 목차구성은 다음과 같습니다.

1. 쟁점의 정리

2. 상속인 甲·丙·丁의 공동소송의 형태

- A의 사망으로 甲, 丙, 丁이 A의 권리의무를 당연승계하며, 이 경우 법정상속분에 따라 공유관계가 형성되므로 통상공동소송에 해당합니다.

3. 甲의 이 사건 수계신청의 적법 여부

- (1) 수계신청의 의의 및 요건 - 항소심 계속 중 A가 사망하였고, 소송대리인이 없다고 하였으므로, 소송절차는 중단된 상태입니다.
- (2) 甲단독의 수계신청 가부 - A의 사망으로 공동상속인 3인의 통상공동소송으로 전환되며, 특히 통상공동소송의 경우 제66조가 적용됩니다. 공동소송독립의 원칙에 따라 공동상속인 전원이 수계신청하여야 하는 것은 아니며, 개별적으로 수계신청할 수 있으므로, 甲만의 개별 수계는 적법합니다.

4. 丙 및 丁에 대한 소송의 중단 여부

(1) **판례의 태도** - 소송계속중 당사자인 피상속인이 사망한 경우 공동상속재산은 상속인들의 공유이므로 소송의 목적이 공동상속인들 전원에게 합일확정되어야 할 필요적공동소송관계라고 인정되지 아니하는 이상 반드시 공동상속인 전원이 공동으로 수계하여야 하는 것은 아니며, 수계되지 아니한 상속인들에 대한 소송은 중단된 상태로 그대로 피상속인이 사망한 당시의 심급법원에 계속되어 있다.

(2) 사안의 경우

5. **사안의 해결** - 실전모의고사에서도 유사한 문제를 풀어보았으며, 특히 다수의 상속인들이 등장하는 경우, 통상공동소송 논의로 전환되므로, 공동소송독립의 원칙에 대한 구체적인 내용을 기재하는 것이 필요합니다. 공동소송독립의 원칙에 따라 甲만의 수계신청은 적법하며, 丙과 丁에 대한 관계에서는 판결도 분리되어 선고되며, 여전히 항소심에 중단된 채로 소송은 계속된다고 볼 것입니다.

실전모의고사 A반 8회 참고

甲은 乙에게 1억 원(이하 '이 사건 대여금'이라 한다)을 대여하였다는 취지로, 2019. 2. 1. 乙을 상대로 이 사건 대여금의 반환을 구하는 소를 제기하였다. (다음 각 물음은 독립적임)

- (1) 甲은 丙을 소송대리인으로 선임하여 소송을 진행하던 중 사망하였다. 甲의 상속인으로 A, B 및 일본에 사는 C가 있었다. C의 존재를 알지 못한 소송대리인 丙은 A, B에 대해서만 수계절차를 밟아 소송을 계속 진행하였고, 이 사건 소송에 관하여 제1심 법원은 甲의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다. 이 경우 ① 甲으로부터 상소제기의 특별수권을 받은 丙이 A, B만을 항소인으로 표시하여 항소한 경우와 ② 甲으로부터 상소제기의 특별수권을 받은 丙이 항소하지 않고 A와 B만이 직접 항소한 경우를 나누어 항소인으로 표시되지 않은 누락상속인 C가 항소심에서 수계신청을 할 수 있는지 각각 서술하시오. (15점)

(2) 甲과 丙, 丁이 그 소송을 수계하였는데, 甲은 2024. 3. 30. 자기 소유인 이 사건 부동산의 1/2공유지분을 丁에게 양도하고 같은 해 5. 12. 丁 명의로 지분소유권이전등기를 마친 다음 2025. 1. 25. 소를 취하하였다. 丁은 이 사건 2025. 4. 20.자 소변경 신청서를 통하여 甲으로부터 양도받은 1/2공유지분에 기한 이 사건 부동산의 인도청구를 추가하고 청구취지를 변경하기에 이르렀다. 항소심 법원은 공유지분의 양도인 甲이 소를 취하하였으므로 재소금지의 효과가 공유지분 양수인 丁에게도 미친다고 판단하였다. 이와 같은 법원의 판단에 잘못이 없는지를 검토하시오. (10점)

설문 (2)에 대한 간단한 해설

제267조 제2항 재소금지의 문제입니다. 출제자의 의도는 재소금지 판단에 대한 잘못만을 묻고 있기 때문에, 중간 과정에서 제시되어 있는 청구변경의 적법 여부는 크게 문제되지 않음을 알 수 있습니다. 재소를 제기할 수 없는 것은 전소의 원고만인데, 사안과 같이 **공유지분을 양도받은 특정승계인의 경우에도 재소금지의 효력을 받는지 여부**가 출제자가 정확하게 묻는 문제이므로, 이에 대하여 내용 기재가 필요합니다. 목차구성은 다음과 같습니다.

1. 쟁점의 정리

2. 재소금지원칙의 의의와 취지

3. 재소금지원칙의 요건과 효과

4. 전후 당사자가 동일한지 여부

(1) **학설 및 판례** - 이에 대하여 재소를 제기할 수 없는 것은 전소의 원고만이며, 특정승계인의 경우 i) 소의 취하사실을 알지 못한 특정승계인에게는 재소금지의 효력이 미치지 않는다는 **부정설**이 있으나 ii) 판례는 특정승계인도 당사자 동일의 요건을 충족한다고 하여 **긍정설**의 입장이다.

(2) 검토 및 사안

5. 권리보호이익이 동일한지 여부

(1) **재소금지에서 권리보호이익의 기능** - 판례의 입장에 따르면 신소와 구소의 당사자와 소송물의 동일성 여부를 넓게 인정하여 자칫 재판청구권을 침해할 우려가 있다. 이에 판례는 권리보호이익으로 완화하려고 한다. 즉, 소제기를 필요로 하는 정당한 사정이 있는 등 취하된 소와 권리보호이익이 동일하지 않은 경우에는 다시 소를 제기할 수 있다.

(2) 소 취하권의 남용의사가 없는 경우 - 소송 계속중 부동산의 공유지분을 양도함으로써 그 권리를 상실한 공유자가 더 이상 소를 유지할 필요가 없다고 생각하고 소를 취하한 것이라면 그 지분을 양도받은 자에게 소취하에 대한 책임이 있다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 공유지분 양수인으로서 자신의 권리를 보호하기 위하여 양도받은 공유지분에 기하여 다시 소를 제기할 필요도 있어 그 양수인의 추가된 청구는 그 공유지분의 양도인이 취하한 전소와는 권리보호의 이익을 달리하여 재소금지의 원칙에 위배되지 아니한다.

6. 사안의 해결 - 법원의 판단에 잘못이 없는지를 검토하는 문제이며, 판례는 특정승계인 포함설의 입장이나 자신의 권리를 보호하기 위하여 다시 소를 제기할 필요가 있어 전소와 권리보호의 이익을 달리하기 때문에 재소금지의 효과가 丁에게도 미친다는 법원의 판단에는 잘못이 있습니다. 재소금지문제는 실전모의고사에서도 많이 풀어보았으며(많은 회차에 걸쳐 문제를 풀어보았기에 실전모의고사 참고자료는 따로 첨가하지 않았습니다), 특히, 사안처럼 당사자의 범위를 판례가 특정승계인까지 넓히면서 발생하는 재판청구권의 침해 우려를 권리보호이익을 통해 완화하고 있음을 반드시 기재하여야 고득점이 가능하다고 강조하였습니다. 즉, 신소제기를 정당화하는 사유들을 모두 기재하는 것도 좋지만, 출제자가 명확하게 제시해 준 위 소 취하권 남용의사 없는 판례를 기재하여야 할 것입니다.

【제3문】 (30점)

甲이 乙을 상대로 구상금 청구의 소를 제기하여 승소판결을 받아 2011. 11. 11 동 판결이 확정되었다. 그 이후 乙이 丙으로부터 돈을 차용하면서 이를 담보하기 위해 2012. 4. 18 丙과 대물반환예약(이하, '제1 대물반환예약'이라 한다)을 체결하고 乙소유의 부동산 공유지분에 관하여 2012. 4. 20. 지분권이전담보가등기(이하, '제1 담보가등기'라 한다)를 설정하였다. 乙이 2012. 9. 16. 위 부동산에 관한 공유물분할이 있은 후 2013. 4. 1. 다시 동일한 내용의 대물반환예약 (이하, '제2 대물반환예약'이라 한다)을 체결한 뒤, 2013. 4. 3. 제1 담보가등기는 해제를 원인으로 하여 말소하였다. 乙은 같은 날 乙의 단독소유로 분할된 부동산에 제2 대물반환예약을 원인으로 하여 새로운 담보가등기(이하, '제2 담보가등기'라 한다)를 설정하고 그 부동산 및 다른 공유자의 소유로 분할된 부동산에 전사된 담보가등기를 모두 말소하였다. (다음 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲이 2014. 10. 9. 乙에 대한 구상금채권을 피보전채권으로 하여 丙을 상대로 제2 대물반환예약이 사해행위에 해당한다며 사해행위 취소의 소를 제기하였으나 甲의 패소 판결이 선고되었다. 그 이후 甲은 항소하였으며, 항소심은 제2 대물반환예약은 제1 대물반환예약에 기한 이 사건 분할 전 토지 지분에 관한 제1담보가등기를 공유물분할에 따라 이 사건 토지에 관한 제2 담보가등기로 이전하기 위한 계약에 불과하므로, 제2 대물반환예약의 체결은 사해행위에 해당하지 않는다고 판단하였다. 甲은 이에 대하여 상고하였고, 상고심은 제2 대물반환예약의 사해행위 요건 구비 여부는 최초의 제1 대물반환예약 당시를 기준으로 판단하여야 하며 사해행위취소 및 원상회복을 구하는 甲으로서 제2 대물반환예약의 취소를 구할 수 있다고 판단하여 환송 전 원심판결을 파기하여 환송하였다. 그리고 甲은 2016. 11. 5. 환송 후 원심에서 제1 대물반환예약의 취소를 구하는 예비적 청구를 추가하였다. 그러나 환송 후 원심은 환송판결의 판단의 기초가 된 사실관계를 그대로 인정하면서도 환송 후 심리과정에서 새로운 사실과 증거를 채택하지 아니한 채 환송 전 원심판결과 동일하게 제2 대물반환예약 자체로 인하여 소외인 乙의 공동담보가 더욱 부족하게 되었다고 볼 수 없다고 판단하여, 제2 대물반환예약이 일반채권자를 해하는 사해행위임을 전제로 한 甲의 주위적 청구를 배척하고, 甲이 환송 후 원심에서 추가한 제1 대물반환예약의 취소를 구하는 예비적 청구는 제척기간 도과를 이유로 각하하였다. 이와 같은 환송 후 원심법원의 판단에 잘못이 없는지 검토하시오. (10점)

설문 (1)에 대한 간단한 해설

제436조 파기환송판결의 기속력의 문제입니다. 사실관계 그대로 출제되었는데, 사실관계를 전부 제시하고 문제가 길 경우, 제가 구체적인 질문을 먼저 보라고 말씀드린 바 있습니다. 이 경우 **문제 안에 답이 있는 경우**가 많기 때문입니다. 즉, '환송 후 원심법원의 잘못'을 통해 제436조를 도출할 수 있어야 합니다. 사안을 보면 상고심이 사해성 여부를 제1 대물반환예약 당시를 기준으로 판단하여야 한다는 이유로 파기환송하였음에도 불구하고, **파기환송심이 여전히 제2 대물반환예약 자체로 사해성 여부를 판단**하였습니다.

파기환송판결의 기속력 일반론을 최대한 자세하게 기재하여 점수를 확보하여야 할 것입니다. 환송 후 원심법원의 잘못과 관련하여 판례 내용 그 자체를 모른다 하더라도 설문에 제시된 사실관계를 활용하여 답안을 기재하는 스킬이 필요합니다. 목차구성은 다음과 같습니다.

1. 쟁점의 정리

2. 파기환송판결 기속력의 의의와 성질

3. 파기환송판결 기속력의 내용과 범위

(1) 기속력의 내용

(2) 기속력의 범위

4. 환송후 원심법원의 기속력 위반 여부

(1) **주위적 청구 부분** - 이 사건의 경우 제2 대물반환예약의 사해행위 요건 구비 여부는 최초의 제1 대물반환예약 당시를 기준으로 판단하여야 하고 제2 대물반환예약의 취소를 구할 수 있다고 판단하여 환송 전 원심의 판단이 위법하다고 보아 환송 전 원심판결을 파기하여 환송하였다. 그럼에도 불구하고 환송 후 원심은, 환송판결의 판단의 기초가 된 사실관계를 그대로 인정하면서도 환송 전 원심판결과 동일하게 제2 대물반환예약 자체로 인하여 소외인의 공동담보가 더욱 부족하게 되었다고 볼 수 없다고 판단하여, 제2 대물반환예약이 일반채권자를 해하는 사해행위임을 전제로 한 원고의 주위적 청구를 배척하였다. 환송 후 원심이 제1 대물반환예약 당시를 기준으로 판단하지 않은 것은 환송판결의 기속력에 반하는 것으로 위법하다.

(2) **예비적 청구 부분** - 문제는 예비적 청구 부분입니다. 누락이 예상되기에 이 부분을 언급한다면 고득점이 될 것이라 생각합니다. 환송 후 원심은 원고가 추가한 제1 대물반환예약의 취소를 구하는 예비적 청구를 제척기간 도과를 이유로 각하하였는데, 대법원의 파기 환송 판결의 이유에는 제척기간 도과와 관련된 내용을 들고 있지 않습니다. 그러므로 환송 후 원심의 판단은 대법원 판결의 기속력에 반하지 않는다고 할 것입니다.

5. **사안의 해결** - 실전모의고사 A반 1회에서 올해 시사적인 이슈도 있어 불의타 대비로 파기환송판결의 기속력에 관한 문제를 풀어보았습니다. 그 때 우려했던 부분은, 과연 파기환송판결의 기속력 쟁점 자체를 도출할 수 있는지 여부입니다. 쟁점제시가 아닌 쟁점도출형 문제의 경우에는 기속력 도출이 쉽지 않기 때문입니다. 2025년 기출 역시 대법원의 환송판결을 발판삼아 파기환송판결의 기속력만 도출할 수 있었다면, 일반론으로 충분히 점수확보가 가능한 문제였습니다. 위 판례 내용을 보시면 사실관계 그대로 제시가 되었기 때문에, 판례 자체를 전혀 알지 못했다 하더라도 사안에 제시된 사실관계를 토대로 답안을 기재할 수 있었을 것이라 생각합니다. 또한 강의 시간에 최근 변리사 문제가 민법적 지식을 끊임없이 요구하고 있다고 말씀드린 바 있고, 올해도 이러한 출제경향이 유지된 듯 합니다(사해행위 여부가 핵심인 사안이며, 민법에서 기록형으로 출제될 법한 내용이었습니다).

(2) 甲이 2014. 10. 9. 乙에 대한 구상금채권을 피보전채권으로 하여 丙을 상대로 사해행위취소의 소 (이하 '제1 사해행위취소소송'이라 한다)를 제기하여 그 소장부분이 2014. 10. 20. 丙에게 송달되었다. 그리고 甲은 2014. 11. 10. 다시 乙에 대한 대여금채권을 피보전채권으로 하여 丙을 상대로 사해행위취소의 소(이하 '제2 사해행위취소소송'이라 한다)를 제기하였다. 그 이후 丙은 2015. 1. 20. 제1 사해행위취소소송 및 제2 사해행위취소소송에 대하여 각 준비서면을 각 제출하였다. 그리고 甲은 2015. 2. 15. 제2 사해행위취소소송에 대해서만 소취하서를 제출하였다. 甲이 제출한 소취하서의 법적 효과를 검토하시오. (10점)

설문 (2)에 대한 간단한 해설

각 물음은 독립적이기 때문에, (1)문과 혼동하지 않는 것이 중요합니다. (1)문에서는 제1 대물반환예약과 제2 대물반환예약이 구체적으로 제시되어 주위적 청구와 예비적 청구에 대한 기속력 위반 여부가 문제된 사안이었습니다.

(2)문은 제259조 중복소송과 제266조 및 제267조 소취하에 관한 문제입니다. 그렇기 때문에 본 문항의 경우 제소기간은 출제자가 크게 문제삼지 않았음을 알 수 있습니다. 설령 제1 사해행위취소소송이 제소기간 도과로 각하될 운명이었다 하여도 실제로 각하되지 않는 한 중복소송의 요건인 전소 계속 중의 요건은 충족되는 것이기에 제2 사해행위취소소송과 관련하여 중복소송과 소취하 논의로 전환된다는 점은 크게 다르지 않다고 생각합니다. 즉, 출제자의 의도는 **구상금채권과 대여금채권이라는 피보전채권을 제시함으로써 소송물이 아닌 공격방법의 추가에 불과하기에 甲의 제2 사해행위취소소송은 중복소송에 해당하게 됨을 전제로, 甲이 제2 사해행위소송에 대해서만 소취하서를 제출한 것에 대한 법적 효과를 묻고 있는 것**을 알 수 있습니다. 즉, 소극적 소송요건의 흠 등으로 적법한 소가 아니어서 각하판결이 선고될 운명에 있는 경우에도 소취하의 대상이 되어 피고의 동의가 필요한지 여부를 묻는 문제라고 생각합니다. 목차구성은 다음과 같습니다.

1. 쟁점의 정리

2. 제2 사해행위취소소송의 적법 여부

- (1) 중복소송금지원칙의 의의와 취지
- (2) 중복소송금지원칙의 요건과 효과
- (3) 피보전채권을 추가·변경한 경우

1) 판례의 태도 - 채권자취소소송의 소송물은 민법 제406조 채권자취소권이며, 채권자가 사해행위취소 및 원상회복청구를 하면서 보전하고자 채권을 추가하거나 교환하는 것은 사해 행위취소권과 원상회복청구권을 이유 있게 하는 공격방법에 관한 주장을 변경하는 것일 뿐 이지 소송물 또는 청구 자체를 변경하는 것이 아니므로, 채권자가 보전하고자 하는 채권을 달리하여 동일한 법률행위의 취소 및 원상회복을 구하는 채권자취소의 소를 이중으로 제기 하는 경우 전소와 후소는 소송물이 동일하다.

2) 사안의 경우

3. 제2 사해행위취소소송의 취하 거부

(1) **소취하의 의의 및 요건** - 소송요건의 흠 등으로 적법한 소가 아니라도 취하할 수 있다. 즉 각하판결이 선고되기 전뿐만 아니라 선고된 후라도 판결이 확정되기 전까지는 소를 취하할 수 있다.

(2) **피고 동意的 필요 여부** - 피고가 본안에 관한 응소, 즉, 본안에 관하여 준비서면을 제출하거나 변론준비기일에서 진술하거나 변론을 한 경우에는 피고의 동의를 받아야 한다.

4. 제1 사해행위취소소송과 재소금지 - 전소와 후소의 소송물이 동일하고, 후소가 중복소송에 해당하지만 후소가 각하되지 않은 상태에서 본안의 종국판결이 선고된 뒤에 후소인 중복소송을 취하하였다면, 오히려 전소가 재소금지에 해당한다고 할 것이나 사안은 중복소송에 해당하는 제2 사해행위취소소송에 대한 본안판결 자체가 없었으므로 제267조 제2항은 문제되지 않습니다.

5. 사안의 해결 - 甲이 제출한 제2 사해행위취소소송의 경우 제1 사해행위취소소송과 달리 피고 丙에게 송달된 일시는 제시되지 않았지만, 제1 사해행위취소소송의 송달이 2014. 10. 20.이고 제2 사해행위취소소송의 소제기 시점이 2014. 11. 10.이므로 소장부분 송달 역시 그 이후에 되었을 것임이 시간상 명백합니다.

소취하의 시기는 소제기 이후 판결이 확정되기까지는 어느 때라도 가능하며, 설령 제2 사해행위취소소송이 중복소송에 해당하여 소극적 소송요건의 흠 등으로 부적법한 소에 해당한다 하더라도 판결이 확정되기 전까지는 취하할 수 있으므로, 甲의 제2 사해행위취소소송의 소취하서의 법적 효과인 소송종료 여부는 피고의 동의 유무에 따라 결정될 것입니다.

이견이 있을 수 있는데, 공격방법의 철회로 보면 피고 丙의 동의는 처음부터 문제되지 않는다는 것입니다. 보론으로 간단하게 기재하는 것도 좋을 듯 합니다. 사안을 보면, 피고 丙이 제1 사해행위취소소송과 제2 사해행위취소소송에 대하여 각 준비서면을 제출하였다고 제시되었으므로, 제266조와 제267조 제1항의 소의 취하 논의로 접근하는 것이 출제자의 의도에 부합하기 때문입니다. 한가지 더, 제1 사해행위취소소송의 경우 제2 사해행위취소소송의 소취하의 법적 효과와 관련하여 제267조 제2항은 문제되지 않는다는 것입니다. 개인적으로 출제자가 이것까지 의도했는지는 의문입니다.

실전모의고사 B반 5회 참고

甲은 乙에 대하여 2024. 1. 1. 변제기가 도래한 2억 원의 대여금 채권을 가지로 있다. (다음 각 물음은 독립적임)

(1) 채무초과 상태에 있던 乙은 2024. 4. 1. 유일한 재산인 X토지를 丙에게 1억 원에 매도하는 내용의 매매계약을 체결하였고, 2024. 5. 1. X토지에 관하여 乙로부터 丙 앞으로 소유권이전등기가 마쳐졌다. 이에 甲은 2024. 8. 1. 대여금 채권을 보전하기 위하여 丙을 상대로 사해행위취소 및 원상회복청구 소송을 제기하였다.

(2) 甲이 乙에 대하여 대여금 채권과는 별개의 구상금 채권을 가지고 있다고 주장하면서 구상금 채권을 보전하기 위하여 2024. 9. 1. 丙을 상대로 위 매매계약이 사해행위에 해당한다는 이유로 새로운 사해행위취소 및 원상회복청구 소송을 제기하였다면 2024. 9. 1.자 소송이 중복제소에 해당하는지 설명하시오. (12점)

(3) 甲은 소송대리인 A를 선임하여 乙에 대한 구상금채권을 피보전채권으로 하여 丙을 상대로 사해행위취소의 소를 제기하였으나 2015. 10. 9. 패소하였고, 甲은 이 판결에 대하여 2015. 10. 23. 항소장을 제출하였다. 원심재판장은 2015. 10. 30. '이 명령을 송달받은 날로부터 7일 안에 인지대 및 송달료를 납부하라'는 내용의 보정명령을 발령하면서 이를 甲의 원심 소송대리인 A에게 송달하였을 뿐 甲에게는 송달하지 아니하였다. 법원은 甲이 원심에 제출한 소송대리인 위임장을 통해 원심 소송대리인 A에게 상소제기에 관한 특별한 권한이 부여된 사실을 확인할 수 있었다. 그 이후 원심재판장은 2015. 12. 10. 甲이 위 기간 내에 인지를 보정하지 않았다는 이유로 항소장각하 명령을 하였다. 이와 같은 원심재판장의 판단에 잘못이 없는지 검토하시오. (10점)

설문 (3)에 대한 간단한 해설

제90조 소송대리인의 권한과 제402조 보정명령 및 항소장각하가 송달과 함께 문제된 사안입니다. 우선 소송대리인의 권한과 관련하여 소송대리인이 상소 제기에 관한 특별한 권한을 따로 받은 경우, 원심재판장이 소송대리인 A에게 인지의 보정을 명할 수 있는지를 논한 후, 이를 본인 甲에게 송달하지 않고 소송대리인 A에게만 송달한 것의 적법 여부에 대한 논의를 거쳐 항소장각하 명령을 한 원심재판장의 판단에 잘못이 있다고 결론을 내리면 됩니다. 목차는 다음과 같습니다.

1. 쟁점의 정리

2. 원심재판장이 상소 제기 수권 있는 소송대리인에게 인지보정을 명할 수 있는지 여부

(1) 판례의 태도 - 소송대리권의 범위는 특별한 사정이 없는 한 당해 심급에 한정되어, 소송대리인의 소송대리권의 범위는 수임한 소송사무가 종료하는 시기인 당해 심급의 판결을 송달받을 때까지라고 할 것이다. 다만 상소제기의 특별수권이 있는 경우에는 판결정본이 송달되어도 소송대리권이 존속하며, 소송대리인이 상소를 제기한 경우에 대리권이 소멸한다. 이 경우 소송대리인에게 상소장을 제출할 권한과 의무가 있으므로, 상소장에 인지를 붙이지 않은 흠이 있다면 소송대리인은 이를 보정할 수 있고 원심 재판장도 소송대리인에게 인지의 보정을 명할 수 있다.

(2) 사안의 경우

3. 당사자 본인이 항소장을 제출한 경우 소송대리인에게 한 보정명령 송달의 적법 여부

(1) 판례의 태도 - 소송대리인이 상소 제기에 관하여 특별한 권한을 따로 받았다고 하더라도, 실제로 소송대리인이 아닌 당사자 본인이 상고장을 작성하여 제출한 경우에는 소송대리인에게 상소장과 관련한 보정명령을 수령할 권능이 없으므로, 원심재판장이 소송대리인에게 보정명령을 송달한 것은 부적법한 송달이어서 그 송달의 효력이 발생하지 아니한다.

(2) 사안의 경우

4. 사안의 해결 - 소장각하명령의 경우, 올해 불의타로 예상한 쟁점이었습니다. 실전모의고사에서 몇 차례 풀어보았으며, 혹시 항고가 문제될 수 있어 재도의 고안과 함께 풀어보았습니다. 특히, 위 [목차 3]의 내용의 근거가 되는 사실관계는 다음과 같습니다.

『재항고인 본인이 상고장을 작성하여 제출한 사실, 원심재판장은 2023. 5. 31. ‘이 명령을 송달받은 날부터 7일 안에 인지대 및 송달료를 납부하라.’는 내용의 보정명령을 발령하면서, 이를 재항고인의 원심 소송대리인인 변호사 소외인에게 송달하였을 뿐 재항고인 본인에게 송달하지 않은 사실, 원심재판장은 2023. 7. 10. 재항고인이 위 기간 내에 인지를 보정하지 않았다는 이유로 상고장 각하명령을 한 사실, 한편 재항고인은 위 변호사 소외인에게 소송대리를 위임하면서 상소 제기에 관한 특별한 권한을 부여한 사실을 알 수 있다. 재항고인의 원심 소송대리인이 상소 제기에 관한 특별한 권한을 따로 받았다고 하더라도 실제로 원심 소송대리인이 아닌 재항고인 본인이 상고장을 작성하여 제출하였으므로, 재항고인의 원심 소송대리인은 상고장과 관련한 보정명령을 수령할 권능이 없다. 따라서 원심이 재항고인의 원심 소송대리인에게 보정명령을 송달한 것은 부적법한 송달이어서 그 송달의 효력이 발생하지 아니하였고, 결국 이 사건 보정명령에서 정한 보정기간이 진행하지 않게 된다.』

이에 따라 사안을 보면 甲이 직접 항소장을 제출하였으므로, 소송대리인 A에게 인지보정명령을 내린 것 자체가 가능한 것은 별론으로, 원심재판장이 항소장각하 명령을 한 판단에는 소송대리권의 소멸 및 송달에 관한 법리를 오해하여 재판에 영향을 미친 위법이 있다는 결론을 내려야 할 것입니다.

실전모의고사 B반 8회 참고

2019. 1. 1. 甲은 乙에게 2억 원을 이자율 연 12%, 변제기는 2019. 12. 31.로 하여 대여하였다. 2020. 4. 1. 甲은 乙을 상대로 위 대여금 2억 원을 지급하라는 대여금반환청구의 소를 제기하였다. (다음 각 물음은 독립적임)

- (2) 제1심 법원의 재판장은 甲이 제출한 소장에 관하여, 인지를 제대로 납부하지 않았다는 이유로 부족한 인지를 납부하라는 내용의 보정명령을 하였다. 甲은 보정명령에서 정한 보정기한 이내에 보정사항을 제대로 이행하지 않았고, 이에 제1심 법원 재판장은 소장을 각하하는 명령을 한 후 그 원본을 법원사무관에게 교부하였다. 甲은 소장각하명령에 대해 즉시항고를 제기하면서 보정명령에 따른 인지를 납부하였다. 甲의 즉시항고가 타당한지 설명하시오. (6점)

【제4문】 (20점)

甲은 2024. 2. 5 乙을 상대로 투자금반환의 소를 제기한 후, 소송계속 중 2024. 5. 4. A에게 이 사건 투자금반환채권을 양도하였다. 그리고 A는 소송계속 중 甲의 승계인이라고 주장하며 위 소송에 참가 신청하였다. (다음 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲의 乙에 대한 위 투자금반환소송은 2024. 12. 20. 변론종결되었으며, 乙은 2025. 1. 15. A에게 이 사건 투자금반환채권의 양도에 대하여 이의를 보류하지 않고 승낙하였다. 위 투자금반환소송은 2025. 2. 20. 甲의 승소판결로 확정되었다. A는 2025. 3. 10. 乙을 상대로 甲으로부터 양도받은 이 사건 투자금반환채권을 행사하여 별소를 제기하였다. 이 경우에 법원이 어떠한 판단을 하여야 하는지 검토하시오. (10점)

설문 (1)에 대한 간단한 해설

제218조 제1항 변론종결 후 승계인의 문제입니다. 채권양도의 경우 변론종결 후 승계인이 되는 시점에 대한 정확한 판례의 내용을 기재해 준 후, 법원의 판단을 묻고 있으므로, 모순금지설에 따라 A의 후소는 부적법 각하판결을 선고하여야 합니다. 목차구성은 다음과 같습니다.

1. 쟁점의 정리

2. 후소 기판력의 작용 및 범위

3. 채권의 양도가 이루어진 경우

(1) **승계의 범위** - 승계인 범위와 관련하여 채권양도는 소송물을 승계한 경우에 해당하므로, 전소 소송물이 물권적 청구권이든 채권적 청구권이든 불문하고 승계인에 해당한다는 점을 간단하게 기재한 후 승계의 시기에 관한 정확한 판례내용을 기재하면 됩니다.

(2) **승계의 시기** - 채권을 양수하였으나 아직 양도인에 의한 통지 또는 채무자의 승낙이라는 대항요건을 갖추지 못하였다면 채권양수인은 채무자와 사이에 아무런 법률관계가 없어 채무자에 대하여 아무런 권리주장을 할 수 없고, 양도인이 채무자에게 채권양도통지를 하거나 채무자가 이를 승낙하여야 채무자에게 채권양수를 주장할 수 있다.

이에 따라 채권양수인이 소송계속 중의 승계인이라고 주장하며 참가신청을 한 경우에, 채권자로서의 지위의 승계가 소송계속 중에 이루어진 것인지 여부는 채권양도의 합의가 이루어진 때가 아니라 대항요건이 갖추어진 때를 기준으로 판단하는 것과 마찬가지로, 채권양수인이 변론종결 후의 승계인에 해당하는지 여부 역시 채권양도의 합의가 이루어진 때가 아니라 대항요건이 갖추어진 때를 기준으로 판단하여야 한다.

(3) 사안의 경우

4. A 청구에 대한 법원의 판결

(1) **학설 및 판례** - 후소에 기판력이 미치는 경우 i) 후소는 부적법 각하를 면치 못한다는 반복금지설이 있으나, ii) 판례인 모순금지설은 전소 승소시 후소는 권리보호의 요건을 갖추지 못하여 부적법 각하하여야 하고, 전소 패소시 후소는 기각하여야 한다고 한다.

(2) 검토 및 사안

5. **사안의 해결** - A가 전소 계속 중에 승계참가를 하였으나, 사실심변론종결 후 채무자 乙이 민법 제450조 및 민법 제451조에 따른 승낙을 하였으므로, 소송계속 중 소송물의 승계와 관련하여 제81조 승계참가는 문제되지 않게 됩니다. 결국 변론종결 후 승계인에 해당함을 이유로 A의 별소제기는 전소 기판력이 미치기 때문에 모순금지설에 따라 부적법 각하판결이 선고된다는 결론을 내리면 됩니다. 실전모의고사에서 기판력과 관련하여 가장 많이 강조했던 부분 중에 하나입니다. 변론종결 후 승계인의 경우 승계인 관련 내용 기재가 핵심이라고 말씀드렸는데, [1문]의 인수승계와 [4문]의 변론종결 후 승계인 모두가 2025년에 출제되었습니다.

실전모의고사 A반 7회 참고

甲은 乙에게 5,000만 원의 대여금채권이 있었고, 변제기가 도래하여도 乙이 이를 지급하지 않자, 乙을 상대로 대여금 청구의 소를 제기하였다. (다음 각 물음은 독립적임)

- (2) 甲은 위 소송계속 중에 위 대여금 채권 5,000만 원을 丙에게 양도하였으나, 사실심의 변론이 종결된 이후에 이러한 사실을 乙에게 내용증명우편으로 통지하였다. 그 후 甲의 청구를 인용하는 판결이 선고되어 그대로 확정되었다(이하 '선행소송'이라 한다). 丙은 자신이 양수받은 5,000만 원의 채권을 지급받기 위하여 乙을 상대로 별도의 소를 제기한 경우(이하 '후행소송'이라 한다), 후행소송의 법원은 어떠한 판결을 하여야 하는지 설명하시오. (14점)

(2) 甲은 주채무자 B에게 투자금반환을 요구하였으나, B가 반환을 거부하자 보증인 丙을 상대로 보증채무이행의 소를 제기하였다. B는 丙을 위하여 위 소송에 참가하였으나 丙의 패소판결이 선고되었다. 이 판결정본은 2025. 5. 27. 丙에게, 2025. 6. 4. B에게 각각 송달되었다. 그리고 丙과 B는 2025. 6. 14. 공동명의로 항소장을 제출하였다. 이 경우에 법원이 어떠한 판단을 하여야 하는지 검토하시오. (10점)

설문 (2)에 대한 간단한 해설

제76조 보조참가인의 소송상 지위에 관한 문제입니다. 승소보조자 입장에서 항소를 제기할 수 있는 바, 이 경우 항소기간의 판단은 피참가인을 기준으로 하여야 한다는 점이 핵심입니다. 보조참가인의 소송상 지위 일반론에 대한 내용과 항소의 적법 여부에 대한 요건을 간단하게 기재한 후 상소기간 논의를 거쳐, **2025. 5. 27.을 기준으로 이미 2주가 초과되어 법원은 항소를 각하**하여야 한다는 판단을 하여야 합니다. 목차구성은 다음과 같습니다.

1. 쟁점의 정리

- 쟁점의 정리 부분에서 주채무자 B의 참가형태가 보조참가인지 여부와 항소요건과 관련하여 항소기간에 대한 내용을 간단하게 제시하여야 합니다.

2. 주채무자 B의 참가형태

- 채권자가 보증채무자를 상대로 제기한 소송에서 보증채무자가 패소하면 주채무자에게 구상청구를 할 것이므로 주채무자가 보증채무자의 승소를 위해 참가하는 경우가 대표적인 보조참가에 해당한다.

3. 보조참가인의 소송상 지위

(1) 독립적 지위

(2) 종속적 지위

4. 보조참가인의 상소의 경우

- (1) **학설 및 판례** - 이에 대하여 i) 참가인을 기준으로 상소기간의 준수여부를 판단하여야 한다는 견해가 있으나 ii) 통설·판례는 상소기간은 피참가인에 대한 판결정본이 송달된 때로부터 진행하고, 참가인에 대한 송달시부터 진행하는 것은 아니라고 하여 피참가인을 기준으로 판단하고 있다. 따라서 보조참가인이 항소장을 제출한 경우에 보조참가인에 대하여 판결정본이 송달된 때로부터 기산한다면 항소기간 내의 항고라 하더라도 피참가인을 기준으로 항소기간이 경과한 것이라면 피고 보조참가인의 항소는 부적법하다고 하였다.

(2) 검토 및 사안

5. 사안의 해결 - 실전모의고사에서도 보조참가 관련 다양한 문제들을 풀어보았는데, 보조참가 문제를 실전모의고사에 출제할 때도 강조한 것이, 최근 보조참가의 출제 경향은 보조참가의 적법 여부 자체는 문제삼지 않는다는 것입니다. 사안을 보면 B의 참가 이후에 패소의 본안판결을 하였음을 알 수 있습니다. 즉, 참가는 적법함을 전제로 항소에 대한 법원 판단만을 묻고 있다는 것입니다. 다만, 2025년 문제는 주채무자 'B는 丙을 위하여 소송에 참가'하였다 고만 제시되어 있으므로, 참가의 형태를 간단하게 논해주어야 고득점이 가능할 것입니다. 그 후 승소보조자의 항소제기와 관련하여 학설과 판례의 내용을 정확하게 기재한 후, 피참가인 丙에 판결정본이 송달된 날인 2025. 5. 27.을 기준으로 이미 2주가 초과되어 2025. 6. 14. 항소장을 제출한 것이 되므로, 법원은 항소를 각하하는 판결을 선고하여야 한다는 결론을 내리면 됩니다.

실전모의고사 A반 4회 참고

丙은 甲에게 2013. 5. 20. 1억 원, 변제기 1년 후로 하여 금전을 빌렸다. 乙이 丙의 채무를 보증하였다. 甲은 변제기가 지나도 丙이 변제를 하지 않자 2014. 6. 20. 乙을 상대로 1억 원의 보증채무 이행을 구하는 소를 제기하였고, 그와 같은 내용이 담긴 소장이 2014. 6. 22. 乙에게 송달되었다. 위 소송계속 중 丙이 乙측에 보조참가신청을 하였고 법원은 허가결정을 하였다. (다음 각 물음은 독립적임)

- (1) 법원은 심리를 마친 후 甲의 청구를 인용하고 이 판결은 2014. 12. 10. 확정되었다. 2014. 12. 12. 그 판결 정본이 피고 乙에게, 2014. 12. 15. 피고 보조참가인 丙에게 각각 송달되었다. 피고 乙은 기한 내에 항소를 하지 아니하였으나, 피고 보조참가인 丙은 2014. 12. 28. 제1심 법원에 항소장을 제출하였다. 위 피고 보조참가인 丙의 항소가 적법한지 설명하시오. (10점)

민사소송법 강평을 마치며

올해 2월부터 의욕적으로 변리사 민사소송법 강의를 시작하면서 실전A와 실전B 모의고사를 모두 진행을 하였습니다. 적중한 문제보다 적중하지 못한 문제에 눈이 가는건 강사입장에서 어찌보면 당연할 것입니다. 한 문제 / 1점 / 0.1점에 당락이 좌우되는 시험에서 학원의 존재가치와 강사의 존재가치는 오로지 시험날 결과로 말해주기 때문입니다. 비가 극한으로 쏟아지고, 천둥번개가 치던 토요일 새벽에 두손 모아 간절히 바랬건만, 제 간절함이 많이 부족했던 것 같습니다.

올해 시험도 민법적 지식을 요구하는 내용들이 다수 출제되었습니다. 최근 채권자대위권의 왕좌는 이제는 채권자취소권에게 넘겨줘야 한다는 것이 과언이 아닙니다. 나아가 사실관계까지 모두 알아야 하는 문제가 3문의 (1)과 3문의 (3)에서 각각 출제되었습니다. 시험을 준비하는 수험생 입장에서 시험장의 체감 난이도가 엄청나게 높았을 것이며, 다른 문제까지 영향을 미칠 정도의 멘탈을 뒤흔들어 놓았을 것으로 생각됩니다(이에 대하여 수업시간에 언급해 드리지 못했는데, 너무 죄송스러울 따름입니다). 3문의 (1)과 (3)은 변리사 출제경향을 알 수 있는 문제라고 생각합니다. 변리사 기출문제를 분석하면서 사실관계를 있는 그대로 출제한 경우가 몇 번 있었습니다(가령, 수취인 불명으로 송달이 문제된 사안이나 소멸시효 관련 최고가 여러번 거듭된 사안 등 다수 존재합니다). 앞으로도 이러한 경향은 계속 유지될 것이라 생각합니다. 어찌보면 단순 판례 결론만을 암기하는 것을 지양하고, 주어진 문제를 통해 답을 이끌어내는 것을 보고자 하는 출제자의 의도일 수도 있습니다. 제가 항상 수업시간에 ‘문제 안에 답 있다’, ‘문제를 잘 읽자’라고 강조하는 것도 이러한 출제경향 때문일 것입니다.

위 해설에 대한 이견이 있을 수 있습니다. 저 역시 토요일 강의를 마치고 문제를 분석하며, 해설을 한 것이라 부족한 부분이 무엇인지, 출제자가 의도한 것을 놓치지 않았는지 더 자세하게 살펴볼 것이며, 추후 더 보완을 하여 모범답안으로 제공해 드릴 예정입니다. 그 외 문제에 대한 의견이 있으신 수험생분들은 bokdori6@hanmail.net 또는 한빛 변리사 사이트로 언제든지 문의주시면 감사하겠습니다. 수험생들과의 의견교환은 언제든지 환영입니다.

극상 난이도의 민사소송법 문제를 푸시느라 정말 고생많으셨습니다. 저는 앞으로도 합격에 도움이 될 수 있는 더욱 좋은 교재와 더욱 좋은 강의를 준비하여 수험생분들을 맞이 하겠습니다.

- 한빛 변리사 민사소송법 담당 **김중연** -